

1005775-65.2013.8.26.0020

Assunto: Direito de Vizinhaça

Magistrado: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... furto de materiais de obra, depredação e tráfico de drogas. Requeru autorização para a obstrução de portas e janelas, instalação e conclusão do muro em volta do imóvel.

Decisão de fls. 294, apresentando quesitos.

Embargos de declaração opostos por Ancelmo Brito e outros, ao qual foi negado provimento.

Laudo pericial de fls. 343/367.

Manifestação dos autores às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

4ª Vara Cível

Rua Tomas Ramos Jordao, Freguesia do Ó - CEP 02736-000, Fone: (11) 3992-5294, São Paulo-SP - E-mail: Nossa_sra_ocv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1005775-65.2013.8.26.0020 - Nunciação de Obra Nova

Requerente:

WILMA APARECIDA CARDOSO DE PINHO e ANCELMO BRITO DE PINHO

Requerido:

NAILDO DOMINGOS PEREIRA e ELZA ARAUJO DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. Daiane Thaís Souto Oliva de Souza

Vistos.

Tratam os autos de Ação de nunciação de obra nova proposta por WILMA APARECIDA CARDOSO DE PINHO e ANCELMO BRITO DE PINHO em face de NAILDO DOMINGOS PEREIRA e ELZA ARAUJO DE LIMA, todos qualificados nos autos. Alegam, em síntese, que são compromissários compradores e possuidores do imóvel onde residem desde 06/2007, e nele vinham soerguendo benfeitorias, para complementar a renda obtida na aposentadoria, e subsistirem com suas filhas. Embora conste como proprietária, nos lançamentos fiscais, Sra. Maria Ondina de Oliveira, quem tem se arvorado proprietários são os réus, sendo que o requerido Naildo iniciou a construção de uma alvenaria que parecer ser mista, pois pela disposição do terreno e da construção afigura-se que haverá galpões comerciais no pavimento térreo e residenciais nos andares superiores. Sempre foi dito pela PMSP que a área do fundo (objeto da obra nova) era remanescente de desapropriação e permitida aos autores a saída de seu veículo pelos lotes dos réus, assim como abertura de janelas para circulação de ar. As plantas fiscais demonstram que no local houve a construção de ruas e praças, o que, em tese, justificaria a impossibilidade de construção de moradias pelos réus, e, de sua vez, a permissão de uso onerosa concedida aos autores, mediante a

tributação do acréscimo. Em meados de 2013, os réus, alegando ser proprietários, remanejaram cerca de 10 caminhões de terra no local, passaram a levantar uma construção sobre o arrimo dos autores e totalmente rente à sua benfeitoria, não se preocupando em respeitar uma faixa mínima para passeio e travessia de transeuntes na calçada, deixando apenas 30 cm de recuo. Após destruírem os canos de esgoto e água servida, obstruírem a passagem de saída dos veículos dos autores, as janelas que permitiram a passagem de ar na garagem e as janelas do primeiro pavimento, onde se localizam os quartos, a lavanderia e a área de serviço, encontram-se na iminência de, em face da altura das paredes anunciadas, contribuírem para que os autores fiquem totalmente desprovidos de ventilação e claridade. O imóvel do nunciado está em desconformidade com o código de obras do Município de São Paulo. Requerem determinar o embargo e a suspensão liminar da obra executada pelos réus, no imóvel declarado a municipalidade como sendo de propriedade de Maria Ondina de Oliveira, com o seu desfazimento ao final, ou, na impossibilidade, conversão em perdas e danos, qual seja, Rua Sebastião Fernandes Palma, lotes 101/102, Jardim São José. Requer que seja determinada a retirada da obstrução da passagem do esgoto do imóvel da rede da coletora Sabesp, circulação de ar nas janelas dos dois primeiros pavimentos dos autores, desobstruindo o acesso de veículos e produtos mantidos pelos autores, no imóvel declarado à municipalidade como sendo de propriedade de MARIA ONDINA DE OLIVEIRA.

A petição inicial veio instruída com os documentos de fls. 1/47.

Decisão de fls. 68/69, deferindo liminarmente o embargo, independente de justificação prévia.

Auto de embargo de obra as fls. 77.

Citado, o requerido Naildo, apresentou contestação (fls. 78/83). Alegou que há mais de 25 anos exerce a posse do lote 103, da quadra "C", do Jardim São Benedito, com animo de dono. Adquiriu o bem, mas o compromisso particular de promessa de compra e venda extraviou. AS desavenças com o autor começaram no ano de 2008, quando ele começou a colocar seus entulhos na sua obra. O autor também tem sua obra confrontando com direito de vizinhança, que abriu suas janelas para os imóveis vizinhos, e não só para o fundo do imóvel, não observou o recuo legal e necessário, razão pela qual nunca conseguiu anistiar sua obra junto a Prefeitura, de modo que todo aquele prédio se encontra registrado na prefeitura regional apenas com 48 metros quadrados. O autor jamais poderia se utilizar da saída regular construída no fundo do seu lote onde neste ato juntamos cópia recente extraída daquele portal, e outras antes da obra, mostrando ainda que a obra em nada coloca em risco o imóvel do nunciante. A rede de esgoto deságua no terreno do requerido clandestinamente. Os demais imóveis têm seus esgotos ligados para frente de suas construções, apenas o autor se recusa a pleitear tal ligação. Requer a suspensão da medida liminar concedida e citação dos antigos proprietários e vendedores Maria Ondina Franco de Oliveira. Requer os benefícios da justiça gratuita. Pugna pela improcedência. Citada, a requerida Elza Araújo de Lima apresentou contestação (fls. 136/141). Alegou que desconhece as razões da demanda, nunca atentou contra o bem dos nunciantes. Por ser pessoa de idade avançada sempre teve ajuda do Ednaldo Augusto Antonioli de Araújo, já falecido e Ednaldo de Araújo Lima, seu irmão. Quando resolveu iniciar as obras, aproveitando a demanda de seu vizinho Naildo, procuraram o nunciante para tomar providências no sentido de desentulhar os imóveis e regularizar o encanamento de esgoto que passa dentro de seu imóvel. Tem várias reclamações quanto ao imóvel do autor que irregularmente construiu seu terreno a mais de 600 metros quadrados, sem se importar com segurança. O imóvel do nunciante confronta em apenas 03 metros de fundo com imóvel nunciado. Requer a suspensão da liminar concedida e citação dos proprietários antigos. Pede os benefícios da justiça gratuita e, por fim, a improcedência da pretensão.

Manifestação dos requeridos às fls. 224/225 apresentando laudo elaborado por profissional de sua confiança (fls. 226/236).

Certidão de oficial de justiça às fls. 240. Constatou que o imóvel dos requerentes possui 04 pavimentos. Só verificou manchas de umidade no solo, sem outros danos aparentes. Solicitou acompanhamento e avaliação de um perito especializado. Foi determinada a produção de prova pericial (fls. 248).

Quesitos por parte do autor às fls. 260/261.

Manifestação da requerida Elza às fls. 267/268, informando que o bem vem sendo objeto de vários atentados, furto de materiais de obra, depredação e tráfico de drogas. Requeru autorização para a obstrução de portas e janelas, instalação e conclusão do muro em volta do imóvel.

Decisão de fls. 294, apresentando quesitos.

Embargos de declaração opostos por Ancelmo Brito e outros, ao qual foi negado provimento.

Laudo pericial de fls. 343/367.

Manifestação dos autores às fls. 371.

Manifestação dos requeridos às fls. 375/378.

Instados à produção de provas, os autores às fls. 395, manifestaram-se pelo julgamento do feito no estado em que se encontram. Os réus, às fls. 396/398, requereram a juntada ao feito de provas emprestadas no processo nº 1006853-60.2014.8.26.0020, caso se entendesse pertinente, com o julgamento antecipado.

Designada audiência de conciliação (fl. 400), infrutífera.

Manifestação dos requeridos às fls. 404/405, noticiando ato de vandalismo no imóvel, um incêndio de autoria desconhecida.

Manifestação do autor às fls. 415, no sentido de que a obra dos réus é irregular. A interdição absoluta com demolição é necessária.

Decisão de fls. 416/417 deferindo a inclusão de Elza como parte requerida.

Indeferido o pedido de citação dos supostos antigos proprietários.

Desistência do autor às fls. 420 quanto ao corréu JOSÉ MIGUEL DE LIMA.

Mandado de constatação às fls. 446, no sentido de ter sido visualizado a estrutura de ferro e tijolos levantados, aparentemente em estado de abandono.

Sentença a fl. 447 julgando extinta, sem exame do mérito, a presente ação em face de José Miguel de Lima.

Os autores às fls. 450/451 opuseram Embargos de Declaração, para acolher e aclarar a omissão na sentença, fazendo constar expressamente que a revogação da liminar refere-se a quem não é parte no processo e não pode sofrer os efeitos da coisa julgada.

Manifestação dos requeridos acerca dos embargos às fls. 457/461, pela rejeição, ratificando-se a revogação da liminar.

Decisão de fls. 625/626, conhecendo dos embargos e dando-lhes provimento para manter a liminar concedida.

Certidão de decurso do prazo para interposição de recurso às fls. 633.

Relatei o necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está suficientemente instruído e dispensa a produção de novas provas.

No mérito, a pretensão deduzida pelo autor é improcedente.

Com efeito, quanto ao suposto direito de utilizar o imóvel cuja obra se pretende embargar para fins de servidão ou passagem forçada, não encontra amparo nos autos.

De fato, a servidão configura direito real sobre imóvel alheio, nascido pela via contratual ou por usucapião, por conveniência e utilidade do prédio requerente, que pode estar encravado ou não, para acesso a alguma via.

O artigo 1.378 do Código Civil dispõe que a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente (pertencente a dono diverso), constituindo-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Ainda sobre o tema, Flávio Tartuce ensina que: "Não se pode esquecer que servidão não se confunde com a passagem forçada. A servidão é facultativa, não sendo obrigatório o pagamento de uma indenização. A passagem forçada é compulsória, assim como é o pagamento da indenização. A servidão é direito real de gozo ou fruição. A passagem forçada é instituto de direito de vizinhança, presente somente na situação em que o imóvel encravado não tem saída para a via pública (art. 1.285 do CC)." (Manual de Direito Civil, 8ª edição, volume único, item 7.8.3, Método, 2018).

Pois bem.

No caso dos autos, considerando que o imóvel do autor não está encravado e não comprovou ele ter direito real de servidão, em quaisquer de suas formas, não tem

direito de passagem pelo imóvel que está na posse dos réus.

Quanto ao esgoto, o laudo pericial também deixou clara a possibilidade de que o escoamento seja feito pelo imóvel do autor, apesar de consignar que haveria maiores custos, não discriminados e nem positivados. Cabia aos autores, neste ponto, demonstrar de maneira indene de dúvidas que estes custos seriam tão elevados a ponto de tornarem inviáveis economicamente as obras em seu próprio imóvel, já que a regra é não se utilizar de bem alheio – não o contrário. Tal onerosidade excessiva não restou positivada a contento. O fato de terem utilizado no passado o imóvel dos réus, salvo hipótese de usucapião – não demonstrada – em nada altera o deslinde do feito.

Vejamos o que consta do laudo pericial produzido em Juízo:

"(...) A partir da análise do quadro tem-se que não há restrição na construção nos recuos frontais, laterais e de fundo e que é permitido construir até 04 vezes a área do terreno, e ainda a edificação deve deixar pelo menos 15% de projeção livre de edificações. Não há restrição quanto à altura da edificação.

Em vistoria, foi verificado que os imóveis envolvidos na presente demanda apresentam uma irregularidade frente a municipalidade, no que se refere aos parâmetros de ocupação. Os imóveis dos réus desrespeitam a taxa de ocupação máxima, que limita a edificação de 85% da projeção do terreno. As construções deveriam deixar 15% do terreno livre de edificação, o que não ocorre. A ocupação ali é de 100%. (...)

"O código de obras apresenta, no item 11 - Compartimentos, seção 2 – aberturas (portas e janelas), as diretrizes de dimensionamento e posicionamento dos vãos das janelas e portas para as obras do município de São Paulo. Esse dimensionamento visa o conforto e segurança dos usuários das instalações, determinando áreas mínimas de ventilação e iluminação as aberturas."

Pontua a perita, todavia, que o critério de posicionamento fica a cargo do Código Civil, concluindo que, nesse ponto, "apenas o imóvel do autor apresenta irregularidade frente ao artigo 1301, uma vez que existe abertura de portão, janelas e ventilações na linha de divisa dos imóveis."

Quanto à servidão de esgoto, após mencionar o artigo 1286 e parágrafo do Código Civil, a Perita conclui, externando opinião e ultrapassando limites da análise técnica: 1. que o autor tem direito garantido de servidão de esgoto através dos lotes dos réus; 2. Que a definição do caminhamento do esgoto dentro do imóvel dos réus é de responsabilidade destes; 3. que a obrigação de arcar com o custo ou executar as obras de servidão inicialmente é do autor, porém caso os réus exijam a instalação seja alterada, deve ser feito às suas custas; 4. não há que se falar em desvalorização dos imóveis dos réus, visto que a obra de esgoto não gera grandes transtornos.

Conclui que a obra dos réus tampou as janelas e portões do imóvel do autor, na divisa dos fundos do imóvel e está impedindo a ventilação em janelas e portão edificados em posição irregular, pelo autor. A responsabilidade de arcar com os custos para instalação da servidão de esgoto que passa pelo imóvel dos réus é destes, uma vez que o autor já havia arcado com custo inicial. A obra do réu encontra-se irregular perante a municipalidade, por ultrapassar o percentual de ocupação máxima permitido.

Em resposta ao primeiro quesito da ré (fls. 364), pontua que é possível que o imóvel dos autores despeje na rede pública coletora de águas e esgoto sem se valer do terreno onde feita a construção dos réus, através de bombeamento de esgoto para a rua Doutor Diogo Canteras Garcia. Porém a solução é de alto custo, e o artigo 1286 do Código Civil garante o direito ao Autor de servidão de esgoto pelo referido terreno, sendo esta a opção mais viável economicamente.

Em resposta ao quesito sexto da ré (fls. 365) esclareceu que a ocupação da suposta servidão de passagem dos autores (portão construído no fundo do imóvel deles que dava acesso para a rua Sebastião Fernandes Palma através do lote dos réus, enquanto ainda não havia a construção nos lotes), não prejudicou o acesso dos autores à rua, que é feito pela forma "oficial", qual seja, rua Doutor Digo Canteras Garcia

(frente).

Em resposta ao quesito décimo da ré, disse a Perita (fls. 366) que não foi possível verificar a posição da caixa de esgoto dos imóveis dos réus e nem se existem despejos de esgoto do terreno do autor para dentro do dos réus e se tais despejos causam prejuízo para o imóvel dos réus.

No entanto, na sequência e de modo contraditório, disse, ao responder ao quesito 11 do réu (fls. 366), que há necessidade de construção de servidão de passagem de esgoto através do imóvel dos réus e no 12 arrematou: "Foi constatada apenas a necessidade de reparação da obra de servidão de esgoto do Autor que passa pelo imóvel dos Réus que, segundo o Autor, foi prejudicada".(grifamos).

Como se vê, quanto à servidão de passagem ou passagem forçada a improcedência da pretensão do autor é cristalina frente ao laudo pericial.

No que se refere à servidão de esgoto, apesar das opiniões lançadas pela Sra. Perita, para além da análise objetiva e técnica, o que se tem de concreto é a possibilidade de opção diversa, ou seja, de que o autor despeje o esgoto e águas pluviais diretamente na rede pública coletora, sem necessidade de valer-se do imóvel em que situada a construção dos réus. Ainda, foi demonstrado que, por opção, a caixa de esgoto foi construída pelos autores na parte mais baixa de seu terreno. Não há prova, nestes autos, de efetiva obstrução da passagem de esgoto dos autores pelo terreno dos réus – as fotografias são insuficientes e a perita parte, segundo consta, do que afirmam os autores, apenas – tampouco resta esclarecido como, nestes quase 10 anos de trâmite processual tem sido o esgoto coletado. Tampouco restou suficientemente demonstrada onerosidade excessiva ou usucapião a justificar imposição de servidão.

Nesse diapasão:

Possessória. Servidão de Passagem. Tubulação de esgoto. Prova pericial que forneceu alternativas à servidão de passagem. Direito que deve ser interpretado restritivamente, somente concluindo-se pela servidão quando outra solução é impossível ou excessivamente onerosa. Sentença mantida. Recurso não provido."

(TJSP; Apelação Cível 0001195-49.2012.8.26.0309; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento:27/01/2016; Data de Registro: 04/02/2016).

Por fim, do laudo pericial extrai-se que a irregularidade constatada quanto ao imóvel do réu (ultrapassou a ocupação de 85% , atingindo 100%), não é causa dos problemas relatados pelo autor, relativos à luminosidade e ventilação, os quais decorrem, sim, do fato de ter erguido sua construção de maneira irregular, sem observar a distancia necessária da linha divisória do terreno, para abertura de janelas (art.1301 do Código Civil).

Não se pode, a pretexto de proteger construção irregular dos autores, tolher-se direitos dos réus.

Ante o exposto, sem prejuízo de providências administrativas relativas à ocupação do terreno em excesso pelos réus, irregularidades que, pelo que consta, se estendem à construção feita pelos autores, atenta aos fundamentos e limites desta demanda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar deferida.

Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 20% do valor atualizado da causa.

Não vislumbro, apesar da sucumbência litigância de má-fé a justificar condenação. Registro que os fundamentos lançados representam o entendimento deste Juízo sendo que embargos de infringentes que se voltem exclusivamente contra o veredicto, fora das hipóteses legais, se interpostos serão punidos, na forma da lei.

Transitada em julgado, aguarde-se por trinta dias. Nada sendo requerido, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de junho de 2022.